

1501863-77.2022.8.26.0540  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella  
Comarca: Mauá  
Foro: Foro de Mauá  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 24/10/2022  
... de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Mauá  
Foro de Mauá  
2ª Vara Criminal  
Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501863-77.2022.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501863-77.2022.8.26.0540  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261520/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 27636638 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, GW4736-1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2261520 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ELCIO DE SOUZA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ELCIO DE SOUZA MOURA foi denunciado por incursão no inciso I do parágrafo 4º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 00h35min, na Rua da Matriz, 14 - Centro, nesta cidade de Mauá, o denunciado tentou subtrair para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisa móvel alheia, consistente em valores contidos no caixa do estabelecimento comercial, pertencente a Osvaldo Ken-Iti Kimoto, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 129) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a exclusão da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, a aplicação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento da confissão e aplicação da fração da tentativa em seu grau máximo, a fixação de regime penitenciário aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

A acusação procede.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-4), boletim de ocorrência (fls. 12-4), ofício (fl.116), além da prova oral colhida.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio (fl.11). Em juízo, manifestou-se (mídia digital).

O policial militar Jonathan, na fase administrativa (fls. 07-8), historiou que: (sic) "No momento dos fatos, junto do meu colega de farda, MARCOS ANTONIO DA SILVA JÚNIOR, com a viatura de prefixo M-30102 (BOPM 914), nós realizávamos patrulhamento ostensivo pela área central, quando via COPOM, recebemos determinação para nos deslocarmos até a RUA DA MATRIZ, 14, CENTRO, pois segundo solicitação feita ao nº 190, lá estaria sendo praticado um furto; lá chegando, vimos que a porta do estabelecimento situado naquele endereço estava danificada, mas não era possível entrar no imóvel; então entramos em contato com o proprietário, o sr. OSVALDO KEN-ITI KIMOTO; ele veio até lá e abriu a porta, possibilitando que a gente adentrasse e avistasse, através do sistema de câmeras, um indivíduo no interior do imóvel, forçando a abertura do caixa, para subtração dos valores que nele estavam guardados; não sei falar se as câmeras gravam; sei que fomos na direção dele e o abordamos; identificamos aquele indivíduo como sendo ELCIO DE SOUZA MOURA, o qual confessou que estava furtando aquele estabelecimento".

No mesmo sentido o depoimento do policial Marcos (fl.09).

Em juízo, o policial Marcos disse que foi irradiado, via Copom, que havia um comércio sendo furtado. No local, viram que a porta estava parcialmente aberta, meia levantada, com indícios de arrombamento, com uma chave de fenda e uma mochila ao lado. Entraram em contato com o proprietário, que pela câmera de monitoramento, viu o réu tentando abrir a gaveta do caixa para subtrair os valores. Após pegarem a chave, entraram e abordaram o acusado dentro do comércio (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pela prova oral colhida, notadamente o depoimento do policial militar. No mais, foi devidamente justificada a ausência de laudo pericial, uma vez que o perito criminal informou que o local dos fatos estava fechado e desprovido de preservação policial (fl.116). Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 2. No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência. 3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.074.222 - MA (2022/0051296-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 21 de junho de 2022).

Portanto, comprovado o delito de furto qualificado.

Passo à dosagem das penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (FA fl. 65 -Ex. 6 -proc. 7001213-12.2012), perfazendo 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda etapa, majoro a reprimenda em mais 1/5, diante da multirreincidência do réu (FA fls. 65-6 -Ex. 7 -proc 7000409-26.2013 e Ex.8 -proc 7000123-38.2019), totalizando 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa.

A multirreincidência justifica referida fração de aumento, maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. 1. Constatada a multirreincidência, admite-se, desde que em decisão concretamente fundamentada, o aumento da pena acima da fração de 1/6 (precedentes). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no HC nº 620.189/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/03/2021)".

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante dentro do comércio, tentando abrir a gaveta do caixa, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessório para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Em que pese respeitável entendimento jurisprudencial em sentido diverso, tenho que a atenuante da confissão espontânea não deve ser aplicada, pois o apelante foi preso em flagrante no interior do terreno da unidade básica de saúde, na posse de ferramentas aptas à concretização do furto. Há incompatibilidade lógica entre prisão em flagrante e atenuação da pena pela confissão espontânea" (TJSP, Ap nº 1502232-08.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 17.10.22) g.n.

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade-

Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o duto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal – Tráfico de drogas – [...] Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do duto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022;

Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decism sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decism, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravo regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n.

545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Na fase final, em razão da tentativa, observado o iter criminis percorrido -o réu estava dentro do comércio e já tinha tentado abrir o caixa do estabelecimento- procede-se a diminuição da pena em 1/3, atingindo-se 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e 08 dias-multa.

O valor do dia multa é o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, face aos péssimos antecedentes do réu, com condenação anterior pelo mesmo delito, inclusive. Pelas mesmas razões não incide o disposto no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELCIO DE SOUZA MOURA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 08 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso I do parágrafo 4º do art. 155 c.c. inciso II do art. 14, ambos do Código Penal.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA